

1502229-61.2021.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... foi beneficiado pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, e apesar do esforço estatal em recuperá-lo tornou a incidir na mesma conduta, tornando maior o grau de reprovabilidade da conduta.

Além disso, referido entendimento encontra eco em julgados proferidos pela Corte Bandeirante. Vejamos:

"Reincidente específico em relação ao tráfico de drogas, daí porque justificável ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502229-61.2021.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502229-61.2021.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2173469/2021 - DEL.SEC.OURINHOS

PLANTÃO, 18736560 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 1256/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS

PLANTÃO, 2173469 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2173469 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS,

1256/21/505 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 136/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Ourinhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO LUCIANO NETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Vistos.

JOÃO LUCIANO NETO, qualificado a fls. 09, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inc. III (praça pública), da Lei nº 11.343/06, porque segundo a denúncia na tarde de 27 de junho de 2021, por volta das 15h30min, na Rua Almiro Cardoso Pereira, 243, Praça da Vila Musa, nesta

cidade e Comarca de Ourinhos, transportava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, para fins de tráfico, 8,86g de maconha, divididas em 03 porções, consoante se verifica pelo laudo de constatação provisória de fls. 22/24, bem como pelo laudo definitivo a ser oportunamente encartado..

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa prévia, com rol testemunhal (fls. 242/249).

A denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2021 pela decisão proferida às fls. 256/260, após o que o réu foi regularmente citado.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, após o que o réu foi interrogado. Ato contínuo foi declarada encerrada a instrução processual, oportunidade em que o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia, enquanto a Defesa, por seu turno, pugnou pela desclassificação da imputação para o crime de porte de droga para consumo pessoal.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O feito teve tramitação regular e inexistem irregularidades a serem corrigidas ou vícios a serem sanados, encontrando-se presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação, motivo pelo qual passo imediatamente ao exame do mérito.

Cuida-se de ação penal em que se imputa ao acusado o crime de tráfico de drogas, a qual merece procedência haja vista que o acervo probatório reunido nos autos corrobora a versão acusatória.

Com efeito, a materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08; auto de exibição e apreensão de fls. 19, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 22/24, laudo definitivo de entorpecentes de fls. 145/148 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 149/231.

A autoria, por sua vez, decorre do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Vejamos.

Os policiais militares José Antonio de Lima Júnior e Igor Alexandre Alves de Souza foram ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, oportunidade em que narraram que estavam realizando patrulhamento pela praça da Vila Musa, por ser local com alta incidência de traficância, oportunidade em que visualizaram o réu em cima de uma bicicleta fazendo contato com um terceiro, o qual recebeu do réu uma porção de drogas e ia entregar a ele uma nota de R\$10,00 que estava nas mãos, no entanto nesse momento o réu, ao perceber a aproximação da viatura policial, saiu andando com a bicicleta pela praça, enquanto o terceiro saiu caminhando para outro lado. Disseram que optaram por abordar o réu, pois sabiam que o terceiro era apenas um usuário de drogas, no entanto ele tentou evitar a abordagem dando voltas pela praça com a bicicleta. Na sequência o réu virou a esquina da rua Almiro Cardoso e retirou do bolso diversas porções de droga, as quais foram arremessadas na rua. Ato contínuo ele foi abordado e questionado sobre o que havia dispensado, oportunidade em que o réu tentou fugir da abordagem, tendo sido necessário o uso de força moderada para conte-lo e algemá-lo. No local da abordagem os depoentes localizaram caído ao solo duas porções de maconha e, escondida debaixo do banco da bicicleta, outra porção da mesma droga. Finalmente informaram que tentaram localizar as porções que ele havia dispensado na esquina, no entanto não conseguiram pois acabou juntando muitas pessoas pela rua, inclusive usuários, que podem ter se apropriado das drogas. Por derradeiro informou que já na CPJ o réu foi submetido a uma revista mais minuciosa, ocasião em que foi localizado dentro da cueca dele a quantia de R\$130,00.

O réu João Luciano Neto, por sua vez, ao ser interrogado, afirmou que a droga era destinada ao seu próprio consumo e havia acabado de comprar da pessoa que os policiais viram na praça, salientando que não conseguiu guardar toda droga debaixo do banco e que por isso parte dela estava guardada no banco e outra parte dentro do bolso. Finalmente disse que o dinheiro apreendido nos autos era fruto de seu trabalho, ressaltando que comprou a bicicleta com o salário recebido e o que tinha

sobrado comprou as três porções de maconha, para uso próprio, e guardou o restando no elástico da cueca.

Em que pese a negativa do réu quanto a prática da mercancia ilícita, os depoimentos dos policiais militares, harmônicos entre si, revelam que ele, na ocasião dos fatos, foi flagrado em uma praça com alta incidência de tráfico, fazendo contato com usuário de drogas, o qual estava entregando ao réu certa quantia em dinheiro enquanto recebia dele uma porção de drogas, no entanto a transação ilícita acabou sendo interrompida no momento em que o acusado notou a aproximação da equipe policial e se evadiu do local, dispensando, durante a fuga, duas porções de maconha, as quais foram recuperadas após a abordagem policial.

Vale ressaltar que não se vislumbrou, em qualquer momento do processado, fatos que pudessem colocar em dúvida a ação policial, ou mesmo desabonassem os depoimentos prestados por essas testemunhas.

Demais disso, é pacífico o entendimento de que os depoimentos dos policiais devem ter o mesmo valor probante que os de qualquer outra testemunha compromissada, mormente quando harmônicos com as demais provas amealhadas aos autos.

Nesse sentido, julgou o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age acionamento ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos [...]"(HC n. 74.608-0, rel. Minc Celso de Mello)

Nesse sentido também destaca decisão de lavra da Corte Bandeirante:

"Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJSP; Apelação Criminal 0013199-80.2013.8.26.0278; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro: 11/06/2018).

Ademais, nota-se que parte da droga foi dispensada pelo réu durante a fuga, enquanto a outra parte foi encontrada escondida debaixo do banco da bicicleta que ele conduzia na ocasião, o que revela que afirmação do réu no sentido de que havia acabado de comprar as três porções de maconha de um indivíduo que acabou fugindo da equipe policial é fantasiosa, pois se de fato isso tivesse ocorrido todo entorpecente estaria junto, ou guardado no bolso do réu ou escondido debaixo do banco da bicicleta.

Na realidade, o fato do réu ter conseguido dispensar apenas duas porções acaba por fortalecer a versão dos policiais, pois mostra que de fato, no momento em que ele notou a aproximação dos policiais e tentou se evadir com a bicicleta, ele estava com parte das drogas nas mãos para entregar para o usuário, enquanto o restante estava guardado para posterior venda.

Outrossim, muito embora o réu tenha afirmado que o montante em dinheiro apreendido com ele na ocasião era fruto de trabalho lícito, não apresentou qualquer elemento de prova para corroborar tal versão.

Dissertando acerca do ônus da prova no processo penal, a doutrina do jurista Renato Brasileiro de Lima, em Manual de Processo Penal, 2015, p. 596/597 nos ensina:

"De outro lado, valendo-se do quanto disposto no Código de Processo Civil, que dispõe que incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 333, inciso II - art. 373, II, do novo CPC), à defesa no processo penal compete o ônus da prova quanto às

excludentes da ilicitude, da culpabilidade, ou acerca da presença de causa extintiva da punibilidade. Assim, se o réu alegar, por exemplo, que se encontrava sob coação moral irresistível, caberá a ele o ônus da prova. De modo semelhante, se o acusado alegar que houve renúncia tácita ao direito de queixa, caberá a ele o ônus da prova quanto à referida causa extintiva da punibilidade (CP, art. I 07, inciso V). Nos mesmos moldes, se o acusado apontar a existência de um alibi, caberá a ele fazer prova de sua alegação[...]

Em suma, enquanto o Ministério Público e o querelante têm o ônus de provar os fatos delituosos além de qualquer dúvida razoável, produzindo no magistrado um juízo de certeza em relação ao fato delituoso imputado ao acusado, à defesa é suficiente gerar apenas uma fundada dúvida sobre causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da culpabilidade, causas extintivas da punibilidade ou acerca de eventual alibi. Há, inegavelmente, uma distinção em relação ao quantum de prova necessário para cumprir o ônus da prova : para a acusação, exige-se prova além de qualquer dúvida razoável ; para a defesa, basta criar um estado de dúvida". De acordo com esse entendimento, verifico que a Defesa não apresentou elementos mínimos para comprovar sua versão ou mesmo para incutir dúvidas na convicção dessa magistrada quanto à origem espúria do dinheiro apreendido com o réu.

Além disso, nota-se que o réu se declarou usuário de drogas no entanto não comprovou minimamente aferir rendimentos suficiente para bancar o próprio consumo, revelando a necessidade de comercializar para manter o vício declarado.

Portanto, diante da fragilidade da versão do réu, sobre a destinação das drogas, não há como privilegiá-la em detrimento da acusatória, a qual, como visto, restou sobejamente comprovada nos autos.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para demonstrar a responsabilidade criminal do réu quanto ao crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Não havendo qualquer outra consideração a ser feita, passo a dosimetria e à fixação da pena, atenta às diretrizes fixadas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Nessa esteira, verifico que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta, é ínsita ao tipo penal. O réu registra uma condenação definitiva anterior, a qual será considerada na fase seguinte como circunstância reincidente (fls. 135/136), bem como uma condenação sem trânsito em julgado, que configura maus antecedentes criminais. Por outro lado, não há nos autos elementos suficientes para análise de sua conduta social ou personalidade. Finalmente anota-se que o crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delitiva em apreço, enquanto que as consequências não se mostram gravosas. Nesses termos, fixo a base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes. Lado outro, incide a agravante da reincidência, que é específica, conforme fls. 135/136. Aqui, cedejo que o Código Penal não estabelece limite mínimo e máximo para o aumento da reprimenda em casos de circunstâncias agravantes.

Por outro lado, esta julgadora não se escusa do entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há diferenciação entre a reincidência específica ou genérica no tocante à fração a ser aplicada em decorrência desta agravante, havendo consenso do montante de um sexto seja qual for a hipótese. Todavia, no caso em apreço estão presentes circunstâncias concretas que determinam o maior agravamento. De acordo com a folha de antecedentes de fls. 135/136, observa-se que o denunciado cumpriu integralmente a condenação anterior, quando foi beneficiado pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, e apesar do esforço estatal em recuperá-lo tornou a incidir na mesma conduta, tornando maior o grau de reprovabilidade da conduta.

Além disso, referido entendimento encontra eco em julgados proferidos pela Corte Bandeirante. Vejamos:

"Reincidente específico em relação ao tráfico de drogas, daí porque justificável o aumento na fração de 1/4, dada a maior reprovabilidade" (TJSP; Apelação Criminal 1501900-52.2019.8.26.0559; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara

de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

“Em que pese a lei não defina o percentual a ser adotado, esta Câmara vem reiteradamente optando por 1/5” (TJSP; Apelação Criminal 1502791-90.2020.8.26.0542; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barueri - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021)

Destarte, tendo como norte os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, agravo em 1/5 (um quinto) a pena anteriormente fixada, a qual passa ao montante 07 (sete) anos de reclusão, além de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria da pena, anoto que restou comprovada a prática da traficância em praça pública, de modo que incide a causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06, razão pela qual aumento a pena acima em 1/6 (um sexto), a qual atinge o patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Finalmente, tratando-se de réu reincidente específico, inviável a aplicação do benefício disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006. Neste sentido, “Na etapa derradeira, impossível o acolhimento da pretensão da defesa, tendo em vista a reincidência do paciente, a qual afasta a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (HC 395.081/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). Desta forma, torno a pena acima em definitiva.

Não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto o réu é reincidente específico (artigo 44, inciso II, § 3º, do CP) e a pena superou o teto de 04 (quatro) anos, (artigo 44, caput, CP).

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se de crime hediondo, a lei impõe a fixação no fechado. Porém, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Nesses termos, observa-se que o réu encontra-se encarcerado preventivamente desde a data do flagrante (27/07/2021), tempo que se mostra insuficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, conforme art. 112, inciso V da LEP, com redação dada pela Lei nº. 13.964/19. Logo, fixo, para ele, o regime inicial FECHADO.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra JOÃO LUCIANO NETO, qualificado a fls. 09, para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inc. III (praça pública), da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente FECHADO, além de 815 (oitocentos e quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Demonstrada a traficância pelo acusado, declaro a perda do valor apreendido, em favor da União, por se tratar de produto de tráfico de drogas, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei 11.343/06.

O réu deve permanecer encarcerado, posto que, através da presente decisão, foi reconhecida a sua responsabilidade pelo crime de tráfico de drogas, mola propulsora de tantos outros delitos que causam desordenada delinquência na sociedade, sendo responsável por sustentar o crime organizado.

Ademais, trata-se de réu reincidente específico, demonstrativo concreto de que pode reiterar na prática delitiva, como se vê às fls. 135/136. Esses elementos denotam profundo envolvimento com práticas ilícitas e a persistência na conduta em questão apesar do esforço estatal para ressocializá-lo.

Não se deslembra, ainda, que fora fixado o regime fechado para o cumprimento

inicial de pena, o que, por si só, é incompatível com o estado libertatis. Deve ser levado em consideração, igualmente, a inexistência de previsibilidade de libertação breve, haja vista a recente modificação trazida pela Lei nº. 13.964/19 recrudesceu as frações para obtenção da progressão de regime. Dessa forma, a manutenção ao cárcere também se mostra imprescindível para garantia da aplicação da lei penal, notadamente considerando a reprimenda efetivamente aplicada ao sentenciado. Portanto, há, concretamente, a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar decretado outrora com base em elementos indiciários que foram confirmados por meio da análise do meritum causae. Em situações semelhantes, a Corte Paulista assim reconheceu:

“Habeas Corpus – Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico – Prolação de r. sentença – Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Sentença que manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente fundamentada – Paciente incurso, em tese, em prática de crime hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada” (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2249810-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeceira da Serra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020) destaquei.

Ante o exposto, o réu não poderá aguardar o resultado de eventual recurso em liberdade. Recomende-se-lhe, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquele Tribunal; b) intime-se o condenado para o pagamento da multa a ele aplicada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extração de certidão e encaminhamento à Procuradoria do Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, ficando consignado que o pagamento da multa imposta somente poderá ser feito em uma única parcela, ou seja, não será admitido parcelamento e c) proceda-se a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, seguindo-se as instruções baixadas pelo Ministério da Justiça para esse fim.

De acordo com o que dos autos consta, deixo de condená-lo(a)(s) às custas processuais.

Expeça-se certidão de honorários.

P.I.C.

Ourinhos, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA